

1500108-51.2022.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... que tem duas passagens pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que saiu da cadeia aproximadamente um ano e que agora só é viciado, portanto nega que estava no bairro da Olaria realizando tráfico.". GABRIEL, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia; chegou nesta Urbe, na data dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500108-51.2022.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500108-51.2022.8.26.0626 - Controle nº 2022/000442

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RIBEIRO BERGAMINI e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 185/187, no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 05h, na Rua Olaria, 248, bairro Olaria, nesta cidade e comarca de São Sebastião, GABRIEL RIBEIRO BERGAMINI, ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS e LUCICLEIDE ALVES DA SILVA, qualificados, respectivamente, às fls. 07, 32 e 49, em unidade de designios, traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, 52 (cinquenta e dois) papелotes de Cannabis sativa L., substância popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 478,65g (quatrocentos e setenta e oito gramas e sessenta e cinco centigramas), 179 (cento e setenta e nove) pedras de cocaína na forma de crack, com peso bruto aproximado de 99,80g (noventa e nove gramas e oitenta centigramas) e 50 (cinquenta) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 51,35g (cinquenta e um gramas e trinta e cinco centigramas), conforme auto de constatação preliminar de fls. 76/77 e auto de exibição e apreensão de fls. 69/70. Em razão destes fatos, os réus GABRIEL RIBEIRO BERGAMINI, ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS e LUCICLEIDE ALVES DA SILVA, qualificados, respectivamente, às fls. 07, 32 e 49, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Presos em flagrante delito, com fundamento nos artigos 282, 310, II e 312, do Código de Processo Penal, os réus tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 131/138).

Recebida a denúncia (fls. 204/205), os réus foram citados (fls. 218, 220 e 272) e apresentaram respostas à acusação (fls. 233/235 e 282/283). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 249/251). Designada audiência, em instrução foi procedido ao interrogatório dos réus e colhido o depoimento das testemunhas arroladas pelas partes (fls. 316/320).

Nada requereram as partes na fase do art. 402 do CPP.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, entendendo provados os fatos narrados na denúncia, ao passo que a Defesa, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva estatal, em conformidade com o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em relação aos três réus, sustentando que os acusados, em juízo, foram peremptórios ao negar a traficância, bem como afirmaram que estavam no local apenas para adquirirem drogas, pois são usuários.

Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu que a pena base seja fixada no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do art. 33, da lei de drogas, em seu grau máximo ao réus Alexandre e Lucicleide.

Quanto ao regime, pugnou que seja fixado regime aberto para o cumprimento de pena aos acusados primários e fixado o regime semiaberto ao réu Gabriel, pois reincidente. Por fim, pugnou que seja substituída a pena corporal por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido é procedente.

A materialidade se evidenciou pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo boletim de ocorrência de folhas 66/68, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 69/70, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 76/77, imagens de fls. 71/75, relatório final de fls. 174/177, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 302/304, bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre a pessoa dos réus.

O policial Joanderlley Pereira Miguel, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: na data dos fatos, juntamente com o colega de farda Cbo Araújo, realizaram a Operação Saturação no bairro da Olaria; ao adentrarem na via avistaram três indivíduos (dois homens e uma mulher) e estes ao perceberem a presença da equipe saíram correndo; a ré Lucicleide correu para uma viela e, ato contínuo, arremessou uma sacola/pochete sobre um telhado; o depoente logrou êxito em detê-la e recuperar a referida sacola/pochete, que continha em seu interior grande quantidade de entorpecentes e certa quantia em dinheiro; o outro indivíduo, Gabriel Ribeiro Bergamini, foi detido por seu colega, Cbo Araújo. À Defensora respondeu: não conhecia a ré Lucicleide; atuava somente na costa sul. No mesmo sentido foram os relatos do policial militar Eduardo Nevile Bustamante de Araújo, em nada divergindo o depoimento de ambos; acrescentou que participou da equipe que realizou a Operação Saturação; avistaram três indivíduos (dois homens e uma mulher), que ao perceberem a presença da equipe saíram correndo; lograram-se êxito em alcançar os indivíduos; os três traziam consigo entorpecentes em pochetes, bem como certa quantia em dinheiro. À Defensora respondeu: naquele horário não havia muito movimento de pessoas; viu somente os três indivíduos correndo pela viela.

GABRIEL RIBEIRO BERGAMINI, em solo policial (fl. 07), narrou que: "[...] alega ser viciado em crack e que havia ido a biqueira para comprar uma pedra de crack, que inclusive conseguiu comprar e pagou a quantia de cinco reais e que enquanto estava lá viu as pessoas saírem correndo e então também correu e logo foi alcançado por um Policial que disse que o que achasse seria dele; o interrogando alega que apenas estava com uma pedra de crack, mas posteriormente o Policial apareceu com uma bolsa de cor cinza e atribuiu a ele a propriedade; o interrogando diz que tem duas passagens pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo que saiu da cadeia

aproximadamente um ano e que agora só é viciado, portanto nega que estava no bairro da Olaria realizando tráfico.". GABRIEL, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia; chegou nesta Urbe, na data dos fatos, por volta de 04 horas; dirigia-se para Ilha Bela, local em que sua filha reside, no entanto, no trajeto, resolveu passar pelo bairro do Olaria para adquirir uma "bucha de maconha para seu consumo e uma pedra de crack"; enquanto o taxista ficou na parte baixa do bairro, o interrogando subiu e adquiriu as porções de entorpecentes, acima mencionadas; enquanto descia o morro, um veículo de cor escura inopinadamente surgiu e quatro indivíduos saltaram do carro; o interrogando correu, mas ao perceber que se tratava de policiais militares, parou e foi abordado; admitiu que encontraram consigo uma porção de maconha e uma pedra de crack; alguns minutos depois foi algemado; uma pochete contendo drogas foi apresentada pelo policiais; afirmaram que o interrogando havia dispensado tais drogas no momento que se evadiu; trabalha como tatuador profissional; possui duas condenações por tráfico de drogas. À Defensora respondeu: possui atividade lícita; o celular do depoente foi apreendido.

ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS, na fase inquisitiva (fl. 32), o réu preferiu manter-se calado. ALEXANDRE, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia; admitiu que trazia consigo algumas porções de entorpecentes, porém, para seu consumo; trabalhava em Ilha Bela; passou pelo local para adquirir drogas antes de ir trabalhar; afirmou que possui deficiência física, e portanto, não poderia ter tentado fugir; não conhecia os policiais e não soube explicar porque estão lhe imputando tal crime imotivadamente; nega que tenha corrido; não conhecia os demais réus; não possui passagem criminal anterior; por conta da quantidade de droga, foi preso.

LUCICLEIDE ALVES DA SILVA, em solo policial (fl. 49), narrou que: "[...] alega ser viciada em cocaína e nesta data estava na viela, num beco, na viela 1 no bairro da Olaria, sendo que lá apareceram Policiais e todos correram; a interroganda correu também, mas foi detida por Policiais que encontraram drogas em cima de um telhado e disseram que era de sua propriedade; a interroganda alega que a droga não era sua; a interrogando alega que comprou três pinos de cocaína por cinco reais cada."

LUCICLEIDE, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou, em síntese, que: negou os fatos; disse que estava naquele local "só pra comprar"; não tem passagem anterior; não conhecia os policiais e não soube explicar porque estão lhe imputando tal crime imotivadamente. À Defensora respondeu: possui três filhos, 15, 13 e 7 anos; estava trabalhando à época dos fatos.

Pois bem.

As declarações dos réus não demonstraram harmonia com a dinâmica dos fatos comprovados nos autos. A versão combinada e apresentada por eles é dissonante do que fora apurado durante a instrução criminal.

Os três réus alegaram que são usuários de entorpecentes, mas nenhum comprovou tal dependência. Nenhuma testemunha foi arrolada para infirmar os uníssonos relatos policiais, ou mesmo para comprovar que exerciam de fato atividade lícita, o que facilmente poderia ser comprovado, ainda que documentalmente. Os acusados afirmaram que não conheciam os policiais que realizaram suas prisões e não souberam explicar porque estão lhe imputando tal crime imotivadamente. Frise-se que informalmente Lucicleide admitiu que estava no local traficando drogas. Percebe-se, enfim, no discurso, o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual a versão por ele apresentada não pode ser aceita.

Dessa forma, a negativa apresentada pelos acusados está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtarem da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Por outro lado, os policiais militares narraram os fatos em conformidade com as provas dos autos. Narraram que, na data dos fatos, encontravam em execução da operação saturação, realizada pela Polícia Militar, e ao diligenciarem pelo bairro dos fatos, conhecido pela comercialização de entorpecentes, três indivíduos foram

avistados em uma viela, sendo dois homens e uma mulher, em atitude suspeita, os quais avistando a viatura policial tentaram empreender fuga, contudo, os policiais lograram êxito em alcançá-los. Lucicleide Alves da Silva ao avistar a viatura policial arremessou uma sacola plástica preta que depois de averiguado o seu conteúdo, foi localizado uma porção de substância análoga à crack e maconha, como também foi encontrada em sua posse uma pochete amarela contendo substância análoga à maconha e crack, bem como aparelho de telefonia móvel e quantia em dinheiro. Com Gabriel Ribeiro Bergamine foi encontrada uma pochete cinza contendo substâncias análogas à maconha, cocaína e crack, além de quantia em dinheiro. Por fim, com Alexandre Ribeiro de Jesus foi encontrada uma pochete preta e uma mochila amarela, contendo as mesmas substâncias e mais quantia em dinheiro. Indagada a respeito das substâncias entorpecente, Lucicleide - informalmente - assumiu aos policiais que realizado o comércio ilegal das substâncias (fls. 04/05).

Ressalte-se, por fim, que a operação saturação ocorreu por volta de 05 horas da manhã, ocasião em que não haviam transeuntes pelo local, conforme ressaltou o PM Miguel. Dessa forma, não há razão alguma para dar crédito à alegação defensiva de que os policiais equivocaram-se ao abordarem tão somente "usuários".

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa dos acusados diante das provas produzidas.

Os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os policiais tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente os réus, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável. Ressalte-se que não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade do testemunho policial.

Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (Resp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO” (TJSPAp.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010) - gn.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o

agente tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF: "A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização". (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Além disso, a quantidade e natureza das drogas apreendidas (52 papélotes de "maconha", com peso bruto aproximado de 478,65g, 179 pedras de cocaína na forma de crack, com peso bruto aproximado de 99,80g e 50 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 51,35g), a forma de acondicionamento, individualizadas e prontas para comercialização (imagens de fls. 71/72), a importância apreendida em notas diversas (R\$ 339,15), as contradições e a inércia dos réus no sentido de provar suas alegações (onus probandi - CPP, artigo 156, caput), evidenciam que as drogas eram destinadas ao consumo de terceiros, não havendo falar-se em insuficiência probatória. Saliente-se que o réu Gabriel é duplamente reincidente específico e que a ré Lucicleide informalmente admitiu estar no local traficando.

Incabível a desclassificação da conduta para a de posse de entorpecentes para consumo pessoal, devendo os réus serem condenados pelo crime de tráfico de drogas, pois suficientes as provas de materialidade e autoria delitivas. Ademais, a quantidade de entorpecentes apreendidos em poder dos acusados e a diversidade revelam que as drogas não se destinavam ao consumo pessoal dos réus. Frise que durante toda a instrução os acusados não comprovaram serem usuários de drogas, tampouco atividade lícita. Ademais, a Defesa também não postulou a desclassificação. Por fim, conforme acima mencionado, o réu Gabriel é duplamente reincidente específico e que a ré Lucicleide informalmente admitiu estar no local traficando.

Resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem o réu de sanção, passo ao cálculo da pena, em conjunto para os acusados Alexandre e Lucicleide, vez que idênticas as circunstâncias.

Alexandre Ribeiro de Jesus e Lucicleide Alves da Silva

Na primeira fase, verifica-se pelas folhas de antecedentes em apenso, que os réus não ostentam maus antecedentes (fls. 96/99). Assim, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Na primeira fase, ainda, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42 da Lei Antidrogas e ao artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, perfazendo, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A propósito da fixação da pena base acima do piso em razão da quantidade de drogas apreendida, já se manifestou a Corte Especial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...) III - No presente caso, o magistrado processante, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, considerou mormente a quantidade elevada de entorpecentes apreendidos com a paciente, vale dizer, 673,24 gramas de maconha, para exasperar a reprimenda-base, em consonância com as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal. IV - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito." (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). In casu, não há que reconhecer desproporção na pena-base estabelecida em um quinto acima do mínimo legal, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. Habeas Corpus não conhecido. (HC 472.695/SP, Rel. Ministro FELIX

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018). GN

Na segunda fase, não há nenhuma atenuante ou agravante genérica.

Na terceira fase, verifico estar presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, levando-se em conta a primariedade do acusados e a ausência de indícios concretos de que se dedicassem às atividades criminosas antes do dia dos fatos ou que integrasse organização criminosa. Dessa forma, diminuo a pena na fração de 2/3, resultando assim uma pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a primariedade e a ausência de maus antecedentes por parte dos acusados, fixo o regime inicial aberto (art. 33, §2º e §3º, CP), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena.

Consoante a Resolução do Senado Federal no 5/2012, tendo em vista a quantidade de pena aplicada e a primariedade, bem como que as circunstâncias judiciais do caso concreto não indicam objetivamente a insuficiência da medida, de per si, estão preenchidos os requisitos do art. 44, caput e §2º, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos de: 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

Gabriel Ribeiro Bergamini

Na primeira fase, verifica-se pelas folhas de antecedentes (fls. 200/202), que o réu ostenta mais de uma condenação com trânsito em julgado. Assim, uma delas (0001664-40.2011 - Tráfico de Drogas) utilizo nesta fase de aplicação da pena na qualidade de mau antecedente, elevando a pena base em 1/6, tornando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na primeira fase, ainda, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42 da Lei Antidrogas e ao artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base majorada em 1/6, pela apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes, perfazendo, em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A propósito da fixação da pena base acima do piso em razão da quantidade de drogas apreendida, já se manifestou a Corte Especial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - (...) III - No presente caso, o magistrado processante, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, considerou mormente a quantidade elevada de entorpecentes apreendidos com a paciente, vale dizer, 673,24 gramas de maconha, para exasperar a reprimenda-base, em consonância com as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal. IV - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito." (AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Rel^a. Min^a. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015). In casu, não há que reconhecer desproporção na pena-base estabelecida em um quinto acima do mínimo legal, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes. Habeas Corpus não conhecido. (HC 472.695/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 29/10/2018). GN

Na segunda fase de aplicação da pena, observo que a réu é reincidente específico (fls. 200/202), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, tornando-a 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e

noventa e três) dias-multa.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena, prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, sendo o réu duplamente reincidente específico, não faz jus ao benefício. Mantida, portanto, a pena fixada na fase anterior, qual seja, 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

O regime inicial será o fechado, sendo o adequado ao cumprimento de pena, diante da dupla reincidência específica e da quantidade de pena aplicada, na forma do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal, uma vez que reincidente o réu. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel.Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência (Art. 44, I e II, CP). Pelo mesmo motivo, sobretudo pela quantidade de pena aplicada, não há que se falar em suspensão condicional da pena (Art. 77, CP). Inexistindo informações sobre o elemento subjetivo necessário à progressão de regime, bem como considerando a quantidade de pena aplicada e o tempo de prisão provisória cumprida pelo acusado, não há detração a ser procedida no momento, para fins de determinação de regime inicial mais brando, nos termos da Lei 12.736/2012. Para tanto, remeto à VEC a aplicação do art. 387, §2º, CPP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência: CONDENO os acusados ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS e LUCICLEIDE ALVES DA SILVA, qualificados nos autos, às penas de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, no regime prisional inicial aberto, e ao pagamento, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistente em 1) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução, e 2) limitação de fim de semana, na forma do art. 48 do Código Penal.

CONDENO o acusado GABRIEL RIBEIRO BERGAMINI, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, no regime prisional inicial fechado por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu. Oportunamente, intime-se para pagamento das multas.

Os réus ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS e LUCICLEIDE ALVES DA SILVA poderão apelar em liberdade, considerando o quantum de pena e regime aplicados, bem como a ausência de fundamentos para a decretação de sua custódia cautelar. Expeça-se alvarás de soltura clausulado em favor dos acusados.

Denego ao acusado GABRIEL RIBEIRO BERGAMINI o direito de apelar em liberdade. Ele permaneceu preso durante a instrução em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva, pois concorrentes os motivos ensejadores da prisão preventiva. De fato, o delito de tráfico possui grande perniciosidade social, o qual está sempre associado a uma organização criminosa, em maior ou menor grau de proximidade, e com desdobramentos em outros crimes. Assim, a custódia cautelar do réu é necessária para a garantia da ordem pública. Aliás, se antes do julgamento de mérito que considerou o acusado culpado estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação – TJSP, MS 113.332-3, Rel. Reynaldo Ayrosa. Ademais, há risco concreto de reiteração delitiva, considerando a dupla reincidência específica. Recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Restou demonstrado a origem ilícita do dinheiro apreendido com o réu Alexandre, razão pela qual decreto a sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos

termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Quanto aos objetos e aparelho celular apreendidos, comunique-se a Autoridade Policial para que determine sua destinação, na forma do artigo 516 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça: "Art. 516. Findo o processo, o inquérito policial, o termo circunstanciado ou o procedimento de apuração de ato infracional, não havendo deliberação judicial noutro sentido, será comunicada à Autoridade Policial para que dê destinação aos objetos, na forma dos artigos 120 a 123 e 133 do CPP".

Oficie-se à Delegacia autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Condeno os réus a arcarem com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal dos réus, expeça-se o necessário quanto aos valores, objetos, aparelho celular e às drogas.

Cumpra-se

P.I.C.

Sao Sebastiao, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA